

1014228-95.2021.8.26.0011

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Andrea Ferraz Musa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XI - Pinheiros

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... inspira-se na necessidade de servir a segurança do tráfico jurídico: uma preocupação que se sente com particular intensidade em certos sectores tradicionalmente objecto do direito mercantil, mas a que também importa não ser insensível para além do campo estrito deste. As situações de relevância da aparência desempenham justamente a função de catalisadoras do aludido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

2ª Vara Cível

Rua Jericó s/n, Sala A2/A3, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0497, São Paulo-SP - E-mail: pinheiros2cv@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 26 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos à MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, Dra. ANDREA FERRAZ MUSA.

Eu, _____, escrevente, subscrevi.

SENTENÇA

Processo:

1014228-95.2021.8.26.0011 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Wylma Espinheira Teixeira Ferraz Lima

Requerido:

Itaú Unibanco S.A.

Juiz de Direito: Dra. Andrea Ferraz Musa

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização movida por Wylma Espinheira Teixeira Ferraz Lima em face de Banco Itaú Unibanco S/A.

Aduz a autora que em 14 de dezembro de 2021, por volta das 15:30 horas, recebeu ligação de suposto representante do banco réu, para confirmar transações feitas em seu cartão de crédito.

Segundo tal representante, as compras estariam fora do seu perfil de consumo e demandavam uma investigação.

Afirma que o suposto representante do banco réu possuía todos seus dados pessoais e tinha acesso a todas as compras recentes feitas por ela em seu cartão de crédito.

Assim, sentindo-se surpreendida com a notícia da clonagem do seu cartão, a autora solicitou o bloqueio de seu cartão. Na mesma ocasião, a autora foi informada que o envio do novo cartão ocorreria nos próximos 13 dias. Como a autora entendeu que o prazo era muito longo, pediu uma outra solução.

O suposto representante do banco réu, então, afirmou que só seria possível antecipar o prazo se a autora falasse com sua gerente, Sra. Fernanda (que era de fato o nome da gerente da autora) e fizesse o resgate do código de desbloqueio do seu cartão, recebido por ela há muitos anos e do qual já não o dispunha. Ao informar que não dispunha mais de tal código, a autora foi orientada a abrir o aplicativo do banco, or onde seria possível gera-lo novamente. Alega que nesse ato não houve a geração de qualquer código, sendo que os criminosos conseguiram acesso a todas as suas senhas. Afirmou, ainda, o falso representante do banco, que um motoboy passaria em sua casa para retirar os cartões de crédito e de débito, e que através do chip eles poderiam identificar o código. Assim, a autora entregou seus cartões ao falso portador, aproximadamente às 16:00 horas do dia 14/12/2021. Na posse dos cartões, os autores do delito fizeram saque em dinheiro com cartão de débito (no valor de R\$ 8.500,00) além de inúmeras compras no cartão de crédito (no valor de R\$ 110.997,25). Ressalta que a média de gastos da autora em seu cartão de crédito era em torno de R\$ 3.000,00 ou R\$ 4.000,00. Entende que houve falha no serviço prestado pelo banco réu, vez que seu sistema de segurança não verificou a fraude, não bloqueou compras fora do perfil e permitiu o vazamento de suas informações pessoais bem como informações de sua conta. Alega que houve violação da lei geral de proteção de dados e segurança da informação. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que houve falha no serviço do banco réu, pelo qual responde objetivamente. Pretende a reparação do dano material consistente no saque de R\$ 10.000,00 de sua conta. Pretende, ainda, a declaração de inexigibilidade de débito referente as compras impugnadas apontadas na inicial, que somam R\$ 110.997,25. Aduz que toda a situação causada pelo banco réu lhe causou transtorno excessivo que representa dano moral indenizável, cujo valor estima em R\$ 20.000,00. A tutela antecipada foi indeferida a fls. 95. Todavia, em sede de agravo de instrumento, houve reversão da decisão, sendo deferida a tutela para suspensão da cobrança referente ao débito impugnado na inicial, conforme consta da decisão de fls. 234/235. Regularmente citada, a ré ofertou contestação a fls. 103/123. Nesta alega preliminarmente a necessidade de prova pericial para comprovar a inviolabilidade do chip do cartão da autora. Entende, ainda, necessária audiência de instrução, para colher o depoimento pessoal da autora, já que entende que sua narrativa é confusa e contraditória. Entende que não se deve haver inversão probatória no caso em tela, vez que o banco não agiu com nenhuma modalidade de culpa. No tocante aos fatos, ressalta que foi a autora quem, voluntariamente, entregou o cartão e as senhas aos autores do delito, contribuindo diretamente para a concretização do evento. Trata-se de ato ilícito praticado por terceiro, sendo que o banco réu não tem responsabilidade sobre o mesmo. Ressalta que o evento ocorreu fora da sede bancária, havendo a autora entregue, por sua vontade própria, os cartões e as senhas para os autores do delito, fora do ambiente bancário, sem qualquer ingerência do banco réu. Assim, entende que o banco réu não tem responsabilidade sobre o evento, que ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Afirma que a autora tinha o dever de guarda sobre o cartão e a senha, e esta violou tal dever. Ressalta que todas as mídias alertam sobre esse tipo de golpe, sendo possível à autora tê-lo evitado se houvesse a cautela necessária a tanto. Nega que tenha havido vazamento de dados pelo banco réu. Tratando-se de fato ocorrido por culpa exclusiva da autora, não há qualquer responsabilidade do réu no evento. Ressalta que o seguro contratado cobre prejuízos causados por roubo ou furto qualificado de bens comprados com o cartão segurado e não o ressarcimento de transações realizadas no cartão. Assim, o sinistro não está coberto.

Impugna a existência de dano material, vez que o saque foi realizado com o cartão da autora, mediante a senha do mesmo.

Impugna, ainda, a existência de dano moral e o valor pleiteado a esse título.

Requer a improcedência da demanda.

Houve réplica.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação deve ser julgada antecipadamente, na forma autorizada pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas.

Emerge como fato incontroverso que o autor recebeu telefonema de terceiro que se identificou como funcionário do banco réu e que noticiou suposta fraude de seu cartão de crédito. Importa dizer que o terceiro tinha informações pessoais sobre a autora, seus dados de conta e seus dados pessoais.

Destarte, a autora foi orientada a entregar seus cartões à instituição financeira, mediante um motoboy que retirou o objeto em sua residência. Além disso, foi orientado a entrar em seu aplicativo, sendo que ao que tudo indica, nessa operação os autores do delito obtiveram suas senhas pessoais.

Posteriormente, houve várias transações com seu cartão. Dessa forma, pretende a inexigibilidade da quantia correspondente a todas as compras fraudulentas, devolução dos valores retirados de sua conta e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Tecidas essas considerações, necessário ponderar, inicialmente, que é desnecessária a produção de prova oral ou pericial. Isso porque a controvérsia envolve essencialmente a prova documental anexada aos autos e os fatos narrados são incontroversos. Logo, desnecessária a produção de outras provas.

Com efeito, a prova documental coligida nos autos é suficiente para permitir a compreensão dos elementos principais da dinâmica fática concernente à entrega do cartão, às compras supostamente fraudulentas e à postura das partes, de modo a nortear o livre convencimento judicial motivado.

Neste sentido, José Roberto dos Santos Bedaque leciona:

“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele é o destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando o escopo da atividade jurisdicional, a colheita de elementos probatórios interessa tanto ao juiz quanto às partes” (Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).

Nesse contexto, afigurava-se desnecessário o pretendido depoimento pessoal da autora para o deslinde da causa ou a prova pericial, vez que em momento algum é questionada a inviolabilidade do chip do cartão.

No que concerne ao mérito, a ação é procedente.

Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula nº 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).

O cotejo das alegações fáticas da inicial e do boletim de ocorrência contido nas fls. 91/92 revela que a autora recebeu uma ligação de indivíduo identificado como funcionário do banco réu que o comunicou acerca da ocorrência de possíveis transações fraudulentas. Assim, orientou a autora a cancelar seu cartão, o que supostamente foi realizado.

Em seguida foi orientado a autora que entrasse no aplicativo do banco para resgatar senha para agilizar o atendimento e remessa de novo cartão, quando supostamente os autores do delito obtiveram acesso a suas senhas (fato não impugnado pelo réu). Em seguida, por orientação do referido funcionário, a autora entregou o cartão a um motoboy, que o retirou em sua residência. Essa dinâmica fática foi descrita de forma minudente no Boletim de Ocorrência que instrui a inicial e, frise-se novamente, não foi impugnada pelo réu.

Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a situação fática aduzida pelas partes

deve ser interpretada com fulcro na vulnerabilidade ínsita às relações de consumo, por meio de raciocínio que leve em conta a situação em sua completude, a fim de verificar concorrência de fatos.

Forte nessas premissas, cumpre observar que, embora a autora tenha entregado o cartão ao motoboy, as circunstâncias fáticas conferiam verossimilhança ao telefonema, especialmente considerando que o suposto preposto do banco réu tinha conhecimento de dados pessoais da requerente, da sua conta, incluindo últimas compras e até do nome de sua gerente, sendo este último aspecto fundamental para legitimar a confiança nas condutas supervenientes.

Trata-se das denominadas "circunstâncias unívocas", aptas a conferir uma enganosa percepção da realidade, que, in casu, dizem respeito à condição de preposto aparente do réu (BIRENBAUM, Gustavo. Teoria da aparência. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2012, p. 33-34).

Convém destacar a vulnerabilidade informacional e técnica do consumidor (BENJAMIN, Antonio Herman V; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor, 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2009, p. 73) que, diante das circunstâncias descritas, com confirmação de algumas informações, reputou que se tratava de procedimento interno da instituição financeira.

Outrossim, não há elementos que revelem que a autora efetuou pessoalmente as compras impugnadas, sendo, pois, incabível a afirmação de fato concorrente, com o escopo de minorar a responsabilidade civil do banco requerido.

Com efeito, como é cediço, segundo a súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias".

Com espreque no dever de segurança, ínsito à responsabilidade objetiva (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 155), emerge o dever do fornecedor de evitar fraudes ou artifícios lesivos às movimentações financeiras de seus clientes, o que restou descumprido.

Nesse contexto, importa anotar a relevância da adoção de medidas preventivas, no âmbito do princípio da prevenção que norteia a responsabilidade civil contemporânea (cf. LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Prevenção e Evolução da Responsabilidade Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 24 e ss.; LEVY, Daniel de Andrade.

Responsabilidade civil: De um Direito dos Danos a um Direito das Condutas Lesivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 146).

Neste sentido, o enunciado nº 446 da V Jornada de Direito Civil estabelece: "A responsabilidade civil prevista na segunda parte do parágrafo único do art. 927 do Código Civil deve levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade".

Outrossim, afigurava-se inadmissível exigir que o consumidor duvidasse da lisura daquele procedimento adotado, tendo por base os elementos fáticos descritos pelas partes, à luz das teorias da confiança e aparência, que legitimaram comportamento conclusante e justa expectativa do autor recorrido.

Com efeito, diante da intensidade do tráfego contratual, exige-se segurança jurídica nas relações contratuais: "A tutela da aparência inspira-se na necessidade de servir a segurança do tráfico jurídico: uma preocupação que se sente com particular intensidade em certos sectores tradicionalmente objecto do direito mercantil, mas a que também importa não ser insensível para além do campo estrito deste. As situações de relevância da aparência desempenham justamente a função de catalisadoras do aludido tráfico." (DA FRADA, Manuel António de Castro Portugal Carneiro. Teoria da confiança e responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2004, p. 46).

Neste sentido, tais fatos revelam inoperância do réu no tratamento das informações e da segurança nas operações de seus clientes, intrínsecos à sua cadeia de serviço, afastando a hipótese de fato de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC), restando delineado o denominado fortuito interno ínsito à sua atividade de risco.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresenta

julgamentos com o mesmo entendimento:

“CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO GOLPE DO "MOTOBOY" AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA - Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros, fraudadores Transações que fogem ao perfil da correntista Má prestação dos serviços bancários Responsabilidade objetiva do réu Débitos declarados inexigíveis - Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº 1020727-61.2017.8.26.0003, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 26-07-2018, v. u.).

“Contrato bancário Indenizatória Fraude praticada por terceiro, conhecida como "Golpe do Motoboy" Utilização indevida do cartão de crédito por golpistas Fraude previsível e inerente à atividade bancária Responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços bancários (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ) Procedência, em parte Danos morais não verificados Apelação da autora provida, em parte Apelação do réu não provida, na parte conhecida.” (Apelação Cível nº 1016730-13.2016.8.26.0001, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j. 06-04-2017, v. u.). “RESPONSABILIDADE CIVIL. Transação bancária fraudulenta. "Golpe do motoboy". Inobservância ao perfil de consumo. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade da instituição financeira. Seguro do cartão de crédito, ademais, contratado. Débito inexigível. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº 1011364-19.2018.8.26.0002, 23ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 06-02-2019, v. u.).

Assim, por um lado, procede o pedido de declaração de inexigibilidade das operações fraudulentas operadas. Por outro lado, deverá o banco réu ser condenado a restituir os valores indevidamente retirados das contas da autora.

De outro lado, a ofensa moral reclamada é resultante inexorável dos transtornos, angústia, frustração e abalo psicológico causado à autora em decorrência da fraude praticada por terceiros, mas que somente foi concretizada porque houve falha de segurança do serviço prestado pelo banco réu. É *damnum in re ipsa*, que importuna desde logo o sujeito passivo do injusto desfalque, não se tratando de mero desassossego.

Nesse sentido colhem-se do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Cartão de crédito - Compras realizadas por terceiro sem autorização do autor 'Golpe do Motoboy' - Inversão do ônus da prova - Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14 do CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC) - Ato ilícito e falha na prestação do serviço bancário - Responsabilidade objetiva em decorrência do risco da atividade - Obrigação específica - Cabimento das 'astreintes' para compelir o réu a excluir o débito inexigível da fatura do cartão Inteligência do art. 536, § 1º, do CPC/2015 - Valor que deve ser proporcional à obrigação principal - Necessidade de limitação da multa imposta na sentença - Fixação da multa diária em R\$500,00 em vez de R\$1.000,00 - Montante total da multa diária limitado a R\$15.000,00 em vez de R\$30.000,00 - Dano moral Ocorrência - Prova Desnecessidade - Dano 'in re ipsa' - Fixação da indenização em R\$8.000,00 - Montante razoável - Não houve negatização do nome do autor em rol de inadimplentes, nem protesto de título, tampouco publicidade do fato - Correção monetária desde o arbitramento (cf. Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (cf. art. 405 do CC/02) - Ação indenizatória julgada procedente - Sucumbência do réu. Recurso do autor provido e parcialmente provido o apelo do réu” (TJSP-20ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1038028-58.2016.8.26.0002-São Paulo, J. 08.05.2017, dp à apel. do autor e dpp à apel. do réu, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR).

“Dano moral e material. Relação de consumo, súmula 297 do STJ. Transações indevidas com uso de cartão de crédito e débito. Contexto dos autos que revela falha na prestação dos serviços. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelantes. Danos morais configurados. Quantum mantido. Recurso desprovido.” (TJSP-20ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1010592-87.2016.8.26.0564-São Bernardo do Campo, J. 04.09/2017, np, vu, Rel. Des. LUIS

CARLOS DE BARROS, voto nº 37023).

Configurado, assim, o dano moral, resta fixar o seu quantum.

É certo que, de um lado, há que dissuadir a autora do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação ou transtorno a que acometida.

Não pode, entretanto, o dever reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.

Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em conta o perfil econômico da vítima, a capacidade financeira da entidade ofensora, as circunstâncias do caso concreto e a repercussão social do dano.

Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da razoabilidade, a indenização deve ser fixada em R\$ 5.000,00, quantia a ser corrigida, pelos índices da tabela prática adotada para cálculo dos débitos judiciais, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais de mora desde a citação.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, e julgo extinto o feito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para i. Declarar a inexistência do débito em relação às compras e transações efetuadas que derivam a dívida cobrada pelo réu, tornado definitiva a tutela deferida a fls. 234/234; ii. Condenar o réu ao pagamento da indenização pelo dano material, correspondente aos lançamentos ocorridos nos dois cartões de crédito e na conta corrente da autora, no dia 14/12/2021, que somam o total de R\$ 10.000,00, corrigidos pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 14/12/2021, com juros de mora desde a citação; iii. Condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R\$ 5.000,00, quantia a ser corrigida, pelos índices da tabela prática adotada para cálculo dos débitos judiciais, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais de mora desde a citação.

Em face da sucumbência do réu, condeno-o ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.

P.R.I.

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

D A T A

Em 26 de outubro de 2022

recebi estes autos em Cartório.

Eu, _____, Escr., subsc.